

1501968-52.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Zilli, j. 17.05.2021); e

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de afastamento do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da imposição do retiro pleno - Inviabilidade dos pedidos - Presentes os requisitos do "tráfico privilegiado", deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501968-52.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501968-52.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ARAUJO DA SILVA SOUZA

Juiz de Direito: LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

Matheus Araújo da Silva Souza, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pela suposta prática do seguinte fato delituoso: "Consta dos inclusos autos que, no dia 29 de novembro de 2020, às 01h48, na via pública da Rua da Portuguesa, altura do nº 44, Vila Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Itapevi, MATHEUS ARAUJO DA SILVA SOUZA, qualificado à fl. 11 e 26, envolvendo a adolescente Gabriela Stefany Melo da Silva, transportava, com o fim de tráfico, 24 porções de cocaína, com peso líquido aferido de 11,58 g, 41 porções de "crack", com peso líquido aferido de 12,1 g, e 03 porções de maconha, com peso líquido aferido de 17,6 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisório de fls. 16/19 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, visando encontrar um veículo roubado.

Foi então que presenciaram o denunciado conduzindo o veículo VW/NOVO FOX, de placa FPC8868, cor branca.

Porém, após a equipe deliberar pela abordagem, MATHEUS empreendeu fuga, arremessando uma sacola plástica de cor preta pela janela do carro.

Foi então que, mesmo diante de ordem de parada, o denunciado continuou a fugir, mas

colidiu seu veículo com um ônibus M.BENZ/INDUSCAR APACHE U, de placa CUA0804, cor cinza, na via descrita Acima.

Durante a abordagem, verificou-se que o denunciado estava na companhia da adolescente Gabriela Stefany Melo da Silva.

Retornando ao local onde MATHEUS arremessara a sacola, foi constatado pela equipe que em seu interior havia 24 porções de cocaína, 41 porções de "crack" e 03 porções de maconha.

As circunstâncias da prisão, aliadas a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita."

O acusado foi preso em flagrante em 29/11/2020, tendo sido o respectivo auto homologado, e a ele foi concedida a liberdade provisória (fls. 46/50).

Notificado (fl. 98), o réu apresentou defesa (fl. 96), que não obistou o recebimento da denúncia em 15/03/2021 e o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 103/106.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

Em memoriais, o Ministério Público, entendendo demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do delito, postulou a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, analisando e tecendo comentários acerca da prova acostada, com base na qual vislumbrou a insuficiência de elementos probatórios para emissão de condenação, pugnou pela absolvição, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada impedindo o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e pelos laudos toxicológicos (fls. 16/19, 150/152), que atestam a qualidade entorpecente do material apreendido. As provas técnicas evidenciam a constatação de cocaína e canabinol (THC), substâncias constantes das listas da portaria 344/98 da SVS/MS, sendo, portanto, drogas ilícitas por definição legal (art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06).

A autoria também é certa, emergindo dos depoimentos colhidos no curso da instrução. O policial militar Wandelson Alves de Brito, no distrito policial (fl. 07), relatou que "estava em patrulhamento pela comunidade do Areião, quando se deparou com um veículo VW Fox de branca, que ao avistar a equipe empreendeu fuga em alta velocidade, gerando vários perigos de dano, momento em que visualizou este jogando um saco plástico de cor preta pela sua janela, em ato contínuo continuou o acompanhamento e solicitou apoio via COPOM e pela Rua Portuguesa, na altura do número 44- Jd Santa Rita, o veículo VW Fox colidiu com um ônibus da empresa Benfica, no local em abordagem veicular e pessoal nada de ilícito foi localizado e com apoio de outras equipes retornaram ao local onde foi jogado a sacola e lograram êxito em encontrar o saco de plástico preto jogado pelo motorista, contendo 41 invólucros de substância amarelada análoga a crack, 3 invólucros contendo substância esverdeada análoga a maconha e 24 ependorfs contendo substância em pó de coloração branca análoga a cocaína, que ao indagar o motorista este negou ter jogado algum saco plástico pela janela e a adolescente que o acompanhava informou que também não notou seu namorado jogando uma sacola pela janela do veículo. Durante a detenção o motorista tentou reagir, sendo necessário uso progressivo da força para detê-lo."

O outro policial militar Márcio José Carniel Júnior, na fase de inquérito (fl. 08), narrou que "estava dirigindo a viatura buscando um FOX que havia sido roubado em apoio a outras viaturas de uma ocorrência anterior quando encontramos um veículo FOX que era de outro modelo do que buscávamos. Ao ver a viatura esse carro começou a acelerar forte e fugir, fato que chamou a atenção da equipe. Fizemos o acompanhamento com sinais luminosos e sonoros. Durante o acompanhamento avistei o motorista jogando uma sacola na rua. Pedimos apoio e mais a frente o motorista bateu entre um poste e um ônibus. Deu ré e novamente tentou passar, batendo novamente no ônibus, meu parceiro foi pelo lado do passageiro onde estava uma mulher e eu fui pelo motorista, quando abri a porta, o vidro quebrou. Por um

momento o motorista ainda reagiu a abordagem, sendo necessário uso progressivo da força para detê-lo com uso de algemas. Outra equipe conseguiu recuperar a sacola dispensada e dentro havia diversos entorpecentes. Diante dos fatos, fizemos a detenção e encaminhamos todos para a Delegacia de Polícia."

Em juízo, inquiridos como testemunhas, reproduziram, essencialmente, a narrativa extrajudicial, atestando a veracidade dos fatos imputados na denúncia (mídia audiovisual da audiência).

A adolescente Gabriela Stefany Melo da Silva, ouvida na Delegacia (fl. 09), esclareceu que é "amiga do Matheus, estava no carro indo com ele para uma tabacaria, mas resolvemos voltar e no caminho da minha casa encontramos a viatura. Ele não falou nada e começou a fugir da viatura acelerando. Acabamos sendo fechados por um ônibus e os policiais quebraram o vidro dele. Prenderam ele e me deixaram sentada. Nós fomos na minha casa e buscamos meu pai que está aqui acompanhando tudo, depois para a Delegacia. Eu não vi o Matheus jogando nada para fora do carro. Eu não joguei nada para fora do carro. Ele não usa droga, eu também não uso. Acho que ele fugiu porque não tem habilitação e falou aqui na Delegacia que o carro está atrasado. Fui algemada rapidamente na viatura e depois soltaram. Não gostei que os policiais ficaram me xingando."

Em juízo, reiterou, em substância, o relato extrajudicial.

Por sua vez, a testemunha Gilson César Fogaça, em solo policial (fl. 10), informou que "estava dirigindo um ônibus quando um carro bateu na minha lateral, logo em seguida veio uma viatura que estava perseguindo o veículo e fez a abordagem no carro. Acho que ele queria passar entre o ônibus e a calçada rápido, mas não tinha espaço e bateu na minha lateral. Fiquei no ônibus até ver que a situação tinha acalmado, o inspetor da minha firma veio e conversou com a PM. Depois fui até os policiais e eles disseram que eu teria que vir para a Delegacia. Não presenciei a prisão, apenas vi a movimentação intensa de policiais. O ônibus ficou danificado, mas ninguém se machucou no acidente."

O réu Matheus Araujo da Silva Souza, na delegacia (fl. 11), afirmou: "Estou na presença do meu advogado Edson de Oliveira Ferraz. Minha mãe está ciente da minha prisão. Sou amigo da Gabriela. Eu estava indo com ela em uma tabacaria de Cotia, acabei voltando, fiz o caminho e vi uma viatura. Estava passando com os vidros fechados, eles ligaram o giroflex eu me assustei e comecei a correr. Fui sentido minha casa, ia parar na rua da minha casa. Mas no caminho eu cheguei em um ônibus, não bati no ônibus, aí veio um policial pela minha porta e com a arma quebrou o vidro. Começou a me agredir e disse que por eu ter fugido iria jogar um tráfico em mim. Eles foram e mandaram os rocam voltar, eles nem demoraram muito e já voltaram falando que eu estava com droga, quando apareceram essas drogas. As drogas não eram minhas, eles estão colocando em mim porque eu fugi deles. Apenas fugi porque meu carro está atrasado e fiquei com medo. Os policiais tinham falado para a Gabriela que gravaram em vídeo eu jogando as drogas, mas depois contaram outra versão lá. Sou trabalhador, não uso drogas e não estava portando essas drogas. Não sou traficante."

Interrogado em juízo, o réu repisou a versão prestada em solo policial, enaltecendo que se evadiu da Polícia porque estava com a habilitação vencida, tendo as drogas sido forjadas pela Polícia.

Como se vê, os depoimentos dos policiais apresentaram-se firmes e detalhados acerca do desenrolar da ação ilícita, bem assim no sentido de atribuir sua prática ao acusado. Ambos os agentes públicos, tanto na polícia como em juízo, relataram de forma congruente as razões pelas quais resolveram abordar o acusado, haja vista que, após ordenarem sua parada, empreendeu fuga. Na tentativa de evasão, acabou colidindo com a lateral de um ônibus. Acrescentaram, ainda, terem avistado o acusado, durante a fuga, arremessando uma sacola plástica de dentro do automóvel. A abordagem só foi realizada depois que o réu colidiu o veículo entre um poste e um ônibus. Recuperada a sacola, foram constatados os tóxicos apreendidos. Os policiais esclareceram terem visualizado o momento que o motorista dispensou uma sacola com o carro em movimento.

Os agentes públicos não transpareceram tendenciosidade ou qualquer sorte de motivo

escuso na incriminação do acusado, que sequer conheciam previamente. Onde não é possível, simplesmente, presumir sua parcialidade. Mesmo porque não faria sentido o Estado atribuir a agentes públicos a função de realizar patrulhamento ostensivo e prisões em flagrante, porém negar credibilidade aos depoimentos prestados em decorrência desse mister.

Por seu turno, as alegações do acusado, visando ao reconhecimento da sua inocência, não se apresentam suficientes para mudar o panorama probatório.

O réu negou a prática do crime, especialmente a posse dos tóxicos, dando a entender que a droga foi "plantada" pelos agentes públicos, com objetivo de forjar o cometimento do crime, como forma de punição por ter "fugido" da abordagem. Tal versão, todavia, não é plausível. Como dito, os agentes públicos não conheciam previamente o acusado, de modo que não teriam nada a ganhar pessoalmente com isso, senão risco desnecessário de sofrer sanções penais, administrativas e civis pela hipotética atuação arbitrária.

A alegação de atuação arbitrária dos agentes públicos, atribuindo-lhe droga e conduta da qual não tinha nenhuma relação, apresenta correspondência apenas nas palavras da adolescente Gabriela Stefany - amiga do réu -, que estava no interior do veículo durante a fuga e no momento da abordagem. Mitigada a força probante da versão defensiva que sucumbe aos sólidos elementos acusatórios, conclui-se que a narrativa do réu tem feições de mera tentativa de dissimular a realidade do ocorrido para evitar a responsabilização.

De resto, a defesa não comprovou qualquer fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga eventual tese da absolvição por falta de provas da autoria. Logo, não obstante a argumentação da defesa, os elementos probatórios conferem certeza em desfavor do acusado, isto é, na linha de que, realmente, praticou a conduta ilícita que lhe foi atribuída.

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo, transporte ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal.

Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186).

Noutro giro, é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado, benefício positivado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

O agente é tecnicamente primário, não ostenta maus antecedentes (fl. 160), e não há qualquer sinal de que se dedique a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de maneira que faz jus ao reconhecimento da benesse em tela. No tangente ao patamar de diminuição da pena, malgrado o § 4.º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração redutora, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram a

compreensão de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado – balizas do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 –, servirão para a escolha do quantum da redução.

Considerando que foi apreendida quantidade não portentosa de drogas e que não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social do réu, reputo adequada e proporcional a redução da pena no patamar máximo (2/3). Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Recurso objetivando a aplicação do redutor no grau máximo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório coeso. Confissão. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Condições pessoais favoráveis que comportam a incidência do redutor no grau máximo, a fixação do regime aberto, que melhor se adequa às finalidades preventiva e retributiva da pena, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500290-05.2020.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 16.03.2021).

Também há de ser aplicada a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o acusado envolveu (trouxe para o cometimento do crime) a adolescente Gabriela.

Portanto, está comprovado que, tal como imputado, o réu transportava os entorpecentes apreendidos visando ao tráfico, conduta que se subsume ao tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por isso, e por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena, em atenção ao sistema trifásico (arts. 59 e 68 do CP).

Na primeira fase, tenho que a culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de desabonar quando à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis, ao que se leva em conta variedade de entorpecentes apreendidos e destinados ao comércio, aptos a dar ensejo relevante difusão do vício, potencializando a ofensa à saúde pública, mormente ao ter em conta que correspondiam a cocaína e crack, substância de acentuado poder lesivo e capacidade de viciar. Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima não teve contribuição relevante.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem assim sopesando a especial relevância das circunstâncias descritos no artigo 42 da Lei 11.343/06, arbitro a pena-base em 05 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes a serem consideradas, restando a pena inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, de vez que o delito envolveu adolescente, elevo a pena em 1/6, tendo em vista a participação reduzida da infante, de tal forma que resta estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Também concorre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro a pena em 2/3 (dois terços) – na esteira do acima explanado –, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, reafirmou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, § 1º, da lei 8.072/1990:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.

A dizer: a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo - compreensão que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a posição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. 2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto. 3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD) 2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime aberto para início do resgate da penal corporal, porquanto inferior ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e haja vista que o réu não é reincidente (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, sempre do Código Penal). Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; réu não reincidente em crime doloso; e suficiência e adequação da substituição da pena corporal, diante das circunstâncias judiciais, para atingir as finalidades da sanção), substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do mesmo artigo), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46,

§ 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Em abono ao motivado, colho precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; b) fixação do regime inicial aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prequestionamento.

Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. 2. Dosimetria da pena que merece reparo. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo. Atos infracionais que não constituem elemento impeditivo à aplicação da causa de diminuição. Precedentes. 3. Regime fechado. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Afastamento do caráter hediondo. Precedentes no STF e STJ. Regime aberto que se mostra adequado. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade diante do afastamento do caráter hediondo. Condições subjetivas favoráveis do réu. 5. Pleito de prequestionamento. Desnecessidade de indicação dos fundamentos legais de forma expressa na motivação do acórdão para fins de prequestionamento, desde que haja efetivo debate sobre a matéria. Prequestionamento implícito. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 1501204-56.2020.8.26.0599, 16ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 17.05.2021); e

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de afastamento do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da imposição do retiro pleno - Inviabilidade dos pedidos - Presentes os requisitos do "tráfico privilegiado", deve ser mantida o redutor, bem como os demais benefícios - RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500221-38.2018.8.26.0628, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 17.05.2021). Substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Matheus Araújo da Silva Souza, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período e por prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. Custas pelo condenado (art. 804 do CPP).

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não sobreveio, por ora, razão para modificação dessa condição, ausente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, persistirá livre até o trânsito em julgado ou a superveniência de razões que não mais o recomendem.

Verificada a ligação dos objetos e valores apreendidos com o tráfico de drogas, na forma do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e 63 da Lei 11.343/06, DECRETO seu PERDIMENTO em favor da União. Em consequência, revertam-se os valores em favor do FUNAD e comunique-se a SENAD.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome do réu no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis

ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA